

1500436-46.2021.8.26.0551
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ricardo Truite Alves
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/08/2022

...
A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
3ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500436-46.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500436-46.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2277727/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20767904 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2475/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2277727 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2475/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SUELIO SILVA CAMPOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

SUELIO SILVA CAMPOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, lavrado em decorrência de prisão em flagrante que, na data de 11 de outubro de 2021, por volta das 10h00min, na Rua Guido Marchini Ramello, nº 69, Jardim Senador Vergueiro, nesta cidade e Comarca de Limeira/SP, o acusado adquiriu e mantinha em depósito, para ser entregue a consumo de terceiros, em atividade de tráfico ilícito, 140 flaconetes preenchidos com cocaína, pesando 60,9g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, o denunciado recebeu e mantinha escondido grande quantidade de cocaína no quarto de sua residência, para desenvolver o comércio ilícito de drogas no bairro Jardim Senador Vergueiro e proximidades.

Na data dos fatos, policial militares, em patrulhamento pelo bairro supramencionado, receberam a informação de que um homem conhecido por "Velho" realizava tráfico de drogas e guardava entorpecentes em sua casa. Em razão disso, os agentes públicos dirigiram-se ao imóvel e foram recepcionados por Suelio, o qual confirmou ter o apelido de "Velho" e autorizou a entrada dos policiais na residência.

Durante revista no imóvel, foram localizados, embaixo do sofá da sala, dois pacotes contendo aproximadamente R\$19.638,00 em dinheiro, em notas de cem, vinte, dez e cinco reais. Ainda, na cômoda de um dos quartos, os agentes públicos encontraram 140 porções de cocaína, além de 307 micro tubos plásticos vazios, comumente utilizados para o embalo de drogas.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou o crime.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação do réu para que apresentasse defesa preliminar, que veio aos autos (fls. 82/86).

A denúncia foi recebida em 22 de março de 2022 (fls. 89/91).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

O Ministério Público e a Defensoria Pública ofereceram memoriais escritos.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analiso a preliminar levantada pela Defensoria Pública.

Não há que se falar em ilegalidade da busca domiciliar.

Como se sabe, a inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia.

A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. O contexto de flagrante delito e o estado de necessidade de terceiros (socorro ou desastre) prescindiriam do consentimento expresso do morador.

A configuração do flagrante delito, como se sabe, é uma das hipóteses autorizadoras do ingresso no domicílio alheio. Aqui, no conflito emergente entre a privacidade e o resguardo imediato da ordem pública, o legislador inclinou-se em favor do último.

Da hipótese daquele que é surpreendido no momento em que comete a prática delituosa ou que acaba de cometê-la (flagrante próprio), àquele que é encontrado logo depois, em poder dos objetos ou instrumentos do delito (flagrante presumido), passando pela situação de perseguição imediata e ininterrupta (flagrante impróprio), conferiu o legislador mandamento aos agentes públicos para efetivarem a prisão, independentemente de ordem judicial (art. 302 do CPP).

Ora, se a custódia em tais casos é executada diretamente, natural que o ingresso no domicílio também possa se dar diretamente até mesmo para a concretização daquela prisão.

Então, não houve violação de domicílio, por se tratar o tráfico de drogas de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo.

Não bastasse, cabe ainda chamar a atenção que, no caso concreto, havia fundadas suspeitas da prática de crime do tráfico no local a autorizar a ação da Polícia Militar.

Revelou a prova oral que a diligência policial questionada pela defesa foi precedida de denúncia anônima apontando o local e apelido da pessoa que guardava dinheiro e drogas na sua residência. Na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico ilícito de drogas, quando receberam a informação de que o acusado realizava o tráfico.

No local indicado, os guardas foram atendidos pelo denunciado. A entrada foi franqueada. Indagado, ele confirmou a existência de drogas e dinheiro no interior da sua residência. Em razão desses fatos, houve buscas no interior da residência e os agentes públicos localizaram, dentro da cômoda do quarto do imputado, cerca de 140 flaconetes contendo cocaína, além de 307 microtubos vazios. Ainda, embaixo do sofá da sala, foram localizados pacotes contendo R\$19.638,00 em dinheiro, em notas de cem, vinte, dez e cinco reais.

Em resumo, o réu estava em comportamento típico de tráfico, mas foi interrompido pela ação da polícia militar, havendo prisão em flagrante.

Os elementos trazidos pelos policiais militares corroboraram a fundada suspeita da ocorrência de crime de tráfico no imóvel residencial ocupado pelo denunciado, com o encontro de drogas e vasta quantia em dinheiro, de crime considerado permanente, o que justificou a busca e apreensão sem mandado judicial.

Havendo, portanto, sérios e concretos indicativos da prática de tráfico no local dos fatos, não há que se falar em afronta à tese firmada em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário 603.616 do Colendo Supremo Tribunal Federal (tema 280):

“Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Não é outro o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes, a saber:

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CRIME – FLAGRANTE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, situação de flagrante, surge lícita a entrada forçada em domicílio sem prévia autorização judicial”. (STF, HC 177923, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 03-03-2021 PUBLIC 04-03-2021).

“Agravamento regimental em habeas corpus. Penal. Processo Penal. Crime de tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. Exceção. Situação de flagrante delito. Controvérsia acerca do ingresso de policiais no domicílio (...). 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo

penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (RE nº 603.616-AgR/RG – Tema 280). 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via processual do habeas corpus. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental não provido". (STF, HC 197268 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115 DIVULG 15-06-2021 PUBLIC 16-06-2021).

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. (...) INVOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O presente caso não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, porquanto a entrada na casa foi franqueada pelo ora agravante, ao passo que o referido Tema trata de entrada forçada no domicílio sem mandado judicial. 2. A instância ordinária – soberana quanto à matéria fático-probatória – entendeu que a prisão do agravante se deu em razão da situação de flagrância, e que a apreensão dos aparelhos eletrônicos foi realizada mediante autorização, tudo em conformidade com os depoimentos dos policiais militares. 3. Divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência incabível na estreita via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido". (STF, ARE 1312140 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

"Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, com fundamento nas provas produzidas e submetidas ao contraditório, reconheceram a inexistência de entrada forçada no domicílio do recorrente, identificando a prévia justa causa para o ingresso por parte dos policiais (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STF, HC 198582 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021).

A respeito do consentimento dos moradores, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.342.077/SP (Julgamento: 02/12/2021. Publicação: 06/12/2021), reafirmou a tese fixada no julgamento do RE nº 603.616/RO (Tema 280 de Repercussão Geral), ao assentar:

"O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. O entendimento adotado por essa Suprema Corte impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante".

Na mesma decisão, o Ministro Alexandre de Moraes anulou o venerando acórdão do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021) que exigia consentimento do morador comprovado por documento escrito da diligência policial e gravação audiovisual, eis que tais exigências consubstanciam inovação em matéria

constitucional e implantação obrigatória de medidas não previstas em lei, que são atinentes à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas.

Embora a defesa sustente que a versão judicial do acusado confirmaria a tese de que houve entrada forçada em domicílio, anote-se que o réu confirmou ao ser interrogado na delegacia que franqueou a entrada aos militares (fls. 07).

Desse modo, deve ser dada prevalência ao depoimento dos policiais militares prestados na fase do inquisitivo e do contraditório, que se mostraram firmes e uníssonos quanto ao consentimento do morador, como adiante se verá.

A conduta do denunciado, como mencionada na denúncia, de ter em depósito entorpecente para entrega a consumo de terceiros, caracteriza o delito de tráfico de drogas. É prescindível que o agente seja surpreendido praticando atos de comércio, por não ser a venda a única conduta existente no tipo penal mencionado no artigo 33 da Lei de Tóxicos.

O comércio ilícito de drogas tem na clandestinidade uma de suas principais características, o que dificulta a sua repressão. Os meios usuais de prova (testemunhal e documental) quase sempre se revelam pouco concludentes.

Logo, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas, muito menos em falta de consentimento dos moradores como pretende a combativa defesa.

Não há outras preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), laudo de constatação com resultado positivo para cocaína (fls. 16/18, 58/60 e 113/115), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Interrogado em solo policial, o acusado disse que franqueou a entrada dos policiais em sua residência, os quais encontraram drogas e dinheiro no interior da sua casa. Não deseja revelar maiores detalhes a respeito do ocorrido. Sua ex-esposa tomou ciência da sua prisão e esteve no local (fls. 07).

Em juízo, o acusado disse que tem 52 anos. É gerente de supermercado. É divorciado. Por volta das dez horas da manhã, foi abordado. Não foi denúncia anônima. Pararam a viatura e indicaram sua casa. Estava sentado no sofá com a porta aberta. A viatura retornou. Foi até o portão atender. Perguntaram se ele tinha passagem policial. Não perguntaram se ele tinha drogas na sua casa. Foi pegar seus documentos pessoais. Quando virou eles estavam no interior da sua casa. Em nenhum momento pediram para entrar na sua casa. Não perguntaram se havia entorpecentes. Encontraram porções de cocaína numa gaveta. Havia grande quantia em dinheiro na sua casa em notas diversas. Não autorizou a entrada e nem falou que tinha pino de cocaína. Confirmou que tinha cerca de cinquenta gramas de cocaína na sua casa. Não tem apelido de Velho. Já foi processado e condenado por crime de tráfico de drogas. Não falou que tinha entorpecentes na sua casa. Não é traficante. O dinheiro não é de sua propriedade. As drogas não eram para seu consumo pessoal. O dinheiro é de uma biqueira. Os entorpecentes eram sobras da biqueira, tudo isso seria retirado da sua casa. Guardava as drogas para Bruno, motoboys iriam retirar esse dinheiro e entregar para tal pessoa. Era procurado esporadicamente para guardar as sobras de

drogas e dinheiro porque é pessoa idônea e de mais idade (mídia).

Vejamos o teor da prova oral, em harmonia com a confissão judicial e extrajudicial.

O policial militar Marcelo Farias Lima contou que a equipe estava em patrulhamento quando receberam denúncia anônima apontando uma pessoa de alcunha Velho como guardador de drogas em sua casa no bairro Jardim Senador Vergueiro. Fizeram contato com o réu no local indicado na denúncia. Indagado, ele relatou que seu apelido era Velho. Deram ciência da queixa. O imputado relatou que no interior da sua casa havia apenas um pino de cocaína e já havia cumprido pena por tráfico de drogas. A entrada foi franqueada. Fizeram busca pessoal e nada localizaram. Embaixo do sofá encontraram vasta quantia em dinheiro, era cerca de dezenove mil e seiscentos reais. Ele confessou que o dinheiro era decorrente da venda de drogas. Na cômoda do guarda-roupas foi indicado que havia entorpecentes. Lá localizaram 140 porções de cocaína, assim como 307 pinos vazios. Localizaram uma nota falsa e um celular. Com o recebimento da denúncia foram de imediato até a residência indicada. No local relataram o teor da denúncia, a entrada foi franqueada pelo morador, fizeram primeiro a busca pessoal e depois vistoria no interior do imóvel (mídia).

O policial militar Bruno Ramos de Freitas disse que participou da prisão do acusado. Receberam denúncia anônima a respeito do endereço em questão. O apelido da pessoa envolvida era Velho, não o conhecia até então. A denúncia dizia que havia grande quantidade de dinheiro e drogas naquela residência. Foram até o local indicado. O denunciado estava na garagem, viram ele assim que chegaram. Contaram a respeito da denúncia. Indagado, ele disse de imediato que tinha apenas um pino de cocaína. A entrada foi franqueada, não tem porque mentir. Depois ele contou onde estavam as drogas, seu parceiro achou mais de 300 pinos de cocaína dentro do armário. Embaixo do sofá havia mais de dezenove mil reais em dinheiro trocado. O acusado pediu para entrar em contato com a ex-esposa porque seu filho estava dormindo no quarto. Deixaram ele ligar para sua ex-esposa, o filho não viu o genitor sendo preso. Localizaram vasta quantia de dinheiro e drogas. O delegado ratificou a voz de prisão. Também havia flaconetes vazios (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "latu sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP –

Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

Pelo que se verifica da prova oral colhida, policiais militares estavam em patrulhamento, quando receberam informações de que um homem conhecido por "Velho" realizava tráfico de drogas e guardava entorpecentes em sua casa.

Diante da suspeita, os agentes públicos dirigiram-se ao imóvel e foram recepcionados pelo réu, o qual confirmou o seu apelido e autorizou a entrada dos policiais em sua residência. Em revista no imóvel, foram localizados dois pacotes contendo aproximadamente R\$19.638,00 (dezenove mil seiscentos e trinta e oito reais). Ainda no local, encontraram 140 porções de cocaína, além de 307 flaconetes vazios, comumente utilizados para embalo de drogas.

Houve prisão em flagrante delito.

Dessa forma, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico imputado, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), as circunstâncias e o local da prisão, o depoimento incriminador dos policiais militares e o encontro de vasta quantia em dinheiro, assim como a confissão judicial e extrajudicial, tudo a apontar o réu como pessoa envolvida no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

“Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)” (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Note-se, ainda, que o acusado nada indicou de real para colocar dúvidas sobre a atuação dos policiais militares, pois a abordagem decorreu de uma denúncia anônima e eles sequer o conheciam.

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

“(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)” (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Note-se que o acusado não tinha trabalho lícito e formal ao tempo dos fatos que lhe propiciasse a aquisição de toda aquela quantidade de entorpecente.

Desse modo, demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas.

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A natureza e quantidade de drogas apreendidas no caso em tela não justificam a exasperação da pena-base pois não se trata de quantidade elevada.

Na segunda fase observo que o réu é reincidente específico (Autos nº1500660-32.2020.8.26.0320 – Execução nº 0009329-87.2020.8.26.0502 – Fls. 31/32). Dessa forma, elevo a pena em 1/6, para 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão, com pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por outro lado, como o acusado confessou o delito na delegacia e em juízo e a sua confissão foi utilizada para formação do convencimento do julgador, reduzo a pena ao patamar inicial de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nos termos da Súmula 545 do STJ, "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal", de modo que reconheço a sua incidência ao caso em apreço.

Na terceira fase, não reconheço a existência de bis in idem, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, eis que o acusado é reincidente, em conformidade com jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCENTE. ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. REGIME INICIAL. APLICAÇÃO NOS TERMOS DO DOS ARTS. 59 E 33, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 2. Tratando-se de Paciente reincidente, não faz jus à aplicação da minorante inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06, nem tampouco resta caracterizado bis in idem diante da utilização da reincidência como agravante genérica e como fundamento para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicável apenas ao réu primário e de bons antecedentes. Precedentes (...) 4. Ordem de Habeas Corpus denegada." (STJ, HC 231.511/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, REINCENTE. AGRAVANTE. APLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ORDEM NEGADA. 1. O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2. Reconhecida pelo Colegiado Estadual a reincidência específica do paciente, não há como aplicar a minorante, porquanto não preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse. 3. Não há ilegalidade na utilização da reincidência como agravante genérica e para afastar o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, porquanto é possível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, conforme previsão legal específica. 4. Ordem denegada". (STJ, HC 147.271/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

"PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4º, DA LEI N.º 11.343/2006. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS SEUS REQUISITOS. REINCENTE. AGRAVANTE. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. I - Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois expressamente reconhecido na r. sentença condenatória que o paciente, por ser reincidente, não preenche os requisitos legais. II - Dentro dos limites legais, uma vez configurada a reincidência, a agravante deve ser aplicada. III - Não resta caracterizado bis in idem na utilização da reincidência como causa ensejadora da não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como agravante da pena, ante expressa previsão legal. Habeas corpus denegado". (STJ, HC 148.575/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010).

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva em patamar mínimo legal.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, sobretudo pela natureza e quantidade das drogas em discussão, sem reconhecimento do redutor, além de ser reincidente específico.

Regime diverso do fechado para quem não faz jus ao redutor legal seria de extrema benevolência, por se tratar de crime assemelhado a hediondo.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44, da Lei nº 11.343/2006, além do quantum fixado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar SUELIO SILVA CAMPOS, qualificado nos autos, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que permaneceu preso durante esse processo e ainda persistem os fundamentos que determinaram a prisão, em especial, a necessidade de garantir a ordem pública, ante as nefastas consequências de crimes contra o patrimônio para a sociedade em geral e a probabilidade concreta de solto voltar a praticar a atividade criminosa, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra recolhido, anotando-se que é reincidente específico.

A detração penal será analisada em sede de execução, devendo se verificar a conduta carcerária do réu e os demais requisitos do processo de execução.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial.

Decreto o perdimento do dinheiro e telefone apreendidos, porquanto fruto da traficância ilícita.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados.

Publicado em audiência, saem os presentes intimados.
Limeira, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA